

0000200-11.2018.8.26.0605

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... ainda processos posteriores, inclusive por tráfico de drogas, o que revela sua contumácia e conduta voltada para a criminalidade.

Não obstante, o fato também não pode ser tido como insignificante em razão da presença da qualificadora e da majorante, denotando-se a gravidade concreta da ação.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000200-11.2018.8.26.0605 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000200-11.2018.8.26.0605

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito Policial (Flagrante) - 1009/2018 -

Seccional - Andradina, 1169/2018 - Seccional - Andradina, 75/2018 - 1º Distrito

Policial de Andradina

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS SOARES FREIRE

Justiça Gratuita

O Ministério Público ofereceu denúncia originalmente contra VINICIUS SOARES FREIRE e WAGNER PEREIRA SANCHES imputando-lhes a prática do crime de furto qualificado (Art. 155 §§ 1º e 4º, II e IV c/c Art. 29 "caput" ambos do CP).

Narra a denúncia que no dia 07 de julho de 2018, durante o repouso noturno, na Avenida Barão do Rio Branco, nº 360, nesta cidade e comarca de Andradina, os réus, respectivamente qualificados às fls. 07/10 e 32/34 dos presentes autos, atuando em concurso e com unidade de desígnios, mediante escalada (cf. laudo de fls. 76/78), subtraíram, para eles, 48 (quarenta e oito) unidades de refrigerante, com dois litros cada unidade, marca Funada, distribuídos em oito fardos, avaliados (fls. 18) em R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), pertencentes à vítima Marcos César Belmiro dos Santos.

A denúncia foi recebida em 18 de março de 2019 em decisão de fls. 180/181. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação de fls. 216/220.

O corréu Wagner foi citado por edital e o processo em relação a ele foi desmembrado.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição pela insignificância da conduta, o reconhecimento da tentativa, consideração da confissão espontânea e outros pedidos em relação à aplicação de eventual pena.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls. 02/03, termo de depoimento de fls. 04/07, termo de declarações de fl. 08, termo de interrogatório de fl. 09, boletim de ocorrência de fls. 18/21, autos de exibição e apreensão de fls. 22/23, laudos periciais de fls. 87/89), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada pelos elementos indicados, assim como pela prisão em flagrante e consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

A vítima Marcos César Belmiro dos Santos narrou que estava dormindo e um policial o chamou perguntando se os refrigerantes eram de sua propriedade. Depois, foram à delegacia. Disse que no local há uma parte mais baixa do muro, e tudo leva à conclusão de que ingressaram por essa parte mais baixa.

Guilherme Yoshio Obana Belizaro testemunha e policial militar relatou que foram informados por um transeunte que uma pessoa caminhava na via pública com refrigerantes. Abordaram tal pessoa e se tratava do Vinicius, o qual acabou por confessar que furtara de uma loja de conveniência na companhia de outro indivíduo. Ele indicou uma casa onde estariam os demais refrigerantes. Na casa, contataram o morador, que acompanhou as buscas e nos fundos encontraram mais refrigerantes cobertos. O morador falou que o fato poderia ter sido praticado pelo primo dele, Wagner. Vinicius disse que era o Wagner que havia cometido o fato com ele. Vinicius foi conduzido à delegacia.

A testemunha Nilson Ricardo Trucillo Sanches informou que no dia acordou com a polícia dentro da sua casa, perguntando se alguém havia entrado no local. Quando foram aos fundos, viram que havia dois fardos de refrigerantes e os policiais já foram colocando algemas. Em seguida, levaram sua fotografia para uma pessoa que disse que o depoente não seria o autor dos fatos.

Interrogado, o réu Vinicius Soares Freire confessou os fatos, dizendo que Wagner o chamou para praticar o furto, sendo que escalou o muro do local e entrou, enquanto o depoente ficou na parte de fora e foi pegando os refrigerantes.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de furto qualificado é procedente.

De início, quanto à consumação do furto, assim como para o roubo (súmula 582), o STJ consolidou o entendimento, no sentido da adoção da teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por breve espaço de tempo. Não há a necessidade de o agente ter a posse mansa e pacífica do objeto para configurar o delito. Foi justamente o que ocorreu nos autos.

Confira-se (AgRg no HC 583297 / SC): "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017).

No caso, o réu foi flagrado pela polícia carregando os refrigerantes subtraídos em plena via pública, durante a madrugada. Abordado, assumiu ter praticado furto e indicou o local onde os demais bens subtraídos haviam sido homiziados.

Os policiais então foram ao local e constataram que, nos fundos do imóvel, havia

mais refrigerantes, o que foi confirmado por testemunha absolutamente imparcial - proprietário da residência onde a res furtiva encontrava-se.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Por fim, o réu confessou os fatos, indicando que aderiu à conduta de Wagner, o qual pulou o muro do local.

A escalada foi atestada pelo laudo de fls. 87/89 e o concurso de agentes restou totalmente configurado.

Cabe, ainda, reconhecimento da majorante da prática do crime durante o repouso noturno. Anoto que para a configuração da referida majorante, prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime (AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018).

Certo, ademais, que a recuperação dos bens só se deu por ação da polícia, e não por ato voluntário do réu, sendo inviável se cogitar de qualquer figura em seu benefício. No limite, a recuperação pode ser considerada na dosimetria para que a pena não se eleve, já que as consequências do crime não foram altamente danosas para a vítima.

Inviável também o acolhimento da tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

Nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incidência do princípio depende de uma minuciosa análise de requisitos objetivos, relacionados ao fato, e requisitos subjetivos, vinculados ao agente e a vítima.

Por tais motivos, seu cabimento deve ser avaliado com base nas peculiaridades de cada caso concreto, e não no plano meramente abstrato (Nesse sentido: STF:

HC/123.108/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.08.2015, noticiado no Informativo 793 e STJ: AgRg no RHC 44.461/RS, rel. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 27.05.2014, noticiado no Informativo 542).

O Supremo Tribunal Federal (HC 84.412-0/SP) idealizou quatro requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em apreço, o valor dos bens subtraídos supera os parâmetros normalmente estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para a insignificância, noatadamente a se considerar a data dos fatos (2018) - STJ - AgRg no REsp 1744802 MS 2018/0131490-7 e STJ - AgRg no AREsp 946939 MS 2016/0176618-5.

Some-se a isso o fato de o réu ser reincidente e possuir antecedente criminal por fato anterior ao furto que aqui se analisa e cujo trânsito em julgado se deu poucos dias após a prática do crime (fls. 352/353), apresentando ainda processos posteriores, inclusive por tráfico de drogas, o que revela sua contumácia e conduta voltada para a criminalidade.

Não obstante, o fato também não pode ser tido como insignificante em razão da presença da qualificadora e da majorante, denotando-se a gravidade concreta da ação.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar

que o rompimento de obstáculo para a prática do crime de furto denota a maior reprovabilidade da conduta dos agentes e afasta, por conseguinte, a incidência do princípio da insignificância. 2. O Tribunal regional, ao apreciar o recurso defensivo, decidiu em consonância com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 746.011/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

Por tais motivos, deixo de acolher a aludida tese defensiva.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano.

Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos.

Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas

pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase cabe a exasperação em razão da presença de duas qualificadoras, servindo uma delas como circunstância judicial negativa e a outra como qualificadora em sentido estrito.

Verifico, ainda, que o réu ostenta antecedente criminal, já que cometeu crime anterior ao fato deste processo (03/08/2016), cujo trânsito em julgado para a defesa se deu durante o trâmite deste feito (cinco dias após os fatos 12/07/2018) - fl. 352. Veja-se, o entendimento do STJ sobre a matéria (HC 171212 / DF - 6ª Turma - DJe 20/08/2015): "O conceito de Maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como Maus antecedentes.

Cada uma das circunstâncias será valorada em 1/8. Ressalto que a pena parte do mínimo legal (2 anos) e a este patamar serão somados os montantes das frações encontradas a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a partir da pena mínima.

NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 5 ANOS E NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia

de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020 e AgRg no REsp 1704633/TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019).

Feito novamente tal esclarecimento, adiciono à pena mínima (2 anos) o montante de 1 ano e 6 meses de reclusão, montante equivalente a 2/8 de 6 anos (intervalo de pena previamente estipulado pelo legislador ao considerar globalmente a gravidade do crime - 2 a 8 anos) e estabeleço a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o acusado é reincidente (fl. 353) mas confessou o crime, circunstância levada em conta para a formação da condenação sobre a condenação. Na esteira de já consolidada jurisprudência do STJ (HC n. 365.963/SP), neutralizam-se as circunstâncias.

A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Na terceira fase, diante da majorante prevista no art. 155, § 1º, aumento a pena em 1/3.

Sendo assim, a pena fica em 4 anos e 8 meses de reclusão e 129 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade em concreto do crime (furto duplamente qualificado praticado durante o repouso noturno), quantidade de pena e reincidência, deve ser o fechado (anoto que a súmula 269 do STJ permite o semiaberto a reincidentes desde que a pena não ultrapasse 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam todas favoráveis).

Diante de tais parâmetros, inviável a substituição da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO VINICIUS SOARES FREIRE, pela prática do crime de furto duplamente qualificado, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, c/c art. 29 ambos do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 129 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida, ante as condições socioeconômicas do acusado.

Com o trânsito, i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, ii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado que atuou pelo convênio.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Andradina, 19 de julho de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)